

1502189-17.2020.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Ponte reiterou que o local é ponto de tráfico e o réu estava parado na viela. Abordado, em busca pessoal, com ele não tinha nada. Indagado o que fazia ali, ele confessou o tráfico, a venda de drogas, e indicou uma sacola ali perto com as drogas. Reconhece o réu e não o tinha visto antes da prisão.

Neste sentido foi o depoimento do policial Willian Carrieri alegou que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502189-17.2020.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502189-17.2020.8.26.0537

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308046/2020 - DISE-DEL.SEC.DIADEMA, 15141251 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA, 123/20/301 - DISE-DEL.SEC.DIADEMA, 2308046 - DISE- DEL.SEC.DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Pedro Henrique Fernandes Lobo

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

VISTOS.

PEDRO HENRIQUE FERNANDES LOBO, qualificado à fl. 06, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº11.343/06 c.c. art. 61, II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 14 horas, na Rua Oiroso, n.º 146, bairro Campanário, nesta cidade e comarca de Diadema, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 24 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 12,2 gramas e 47 invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de

91,24 gramas, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20, laudo de constatação provisória de fls. 23/25 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 57/59.

A denúncia foi recebida em 28/02/2022 (fl. 110), sem proposta de transação penal. Concedida a liberdade provisória ao acusado (fl.45/47), seguiu-se com a notificação e citação do réu 95 e 102, a quem foi nomeado Defensor Público que ofertou defesa inicial as fls.107/108.

Em audiência uma foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas Partes, e interrogado o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, entendendo que a pena base deva ser fixada acima do mínimo legal diante da quantidade e variedade de drogas altamente nocivas da cocaína, com a atenuante da menoridade relativa e a agravante da calamidade pública, sem possibilidade de redução da pena nem sua substituição, a cumprida em regime fechado, sem apelo em liberdade.

Já o Defensor Público pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão e da menoridade relativa, afastando-se a agravante da calamidade pública, fixando-se regime mais brando e substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, com direito de apelo em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede em parte, por ser hipótese de se afastar a agravante da calamidade pública, apenas, e como veremos adiante.

A materialidade delitiva vem no auto de exibição e apreensão de fls.23, auto de constatação e definitivo, ambos positivos para as drogas maconha e cocaína (respectivamente às fls. 26/28 e 60/62).

A autoria é inconteste conforme prova que sigo analisando.

Os policiais civis afirmaram em solo pré-processual (fls.05 e 06) que com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, diligenciaram com uma viatura descaracterizada até a Rua Oiroso, próximo ao número 146, Campanário, Diadema/SP, conhecido local de traficância de drogas, onde puderam visualizar um indivíduo parado na lateral da via, na entrada de uma viela, exatamente no local onde costuma ficar a pessoa responsável pela comercialização da droga e decidiram por aborda-lo. Relatou que após a abordagem, identificaram o indivíduo como sendo PEDRO HENRIQUE FERNANDES LOBO, e em busca pessoal nada foi localizado, porém quando questionado, indicou em um canto de um degrau na entrada de uma viela, a aproximadamente um metro onde foi localizada uma sacola plástica com substâncias assemelhadas a drogas no seu interior.

Em juízo o policial Adriano Ponte reiterou que o local é ponto de tráfico e o réu estava parado na viela. Abordado, em busca pessoal, com ele não tinha nada. Indagado o que fazia ali, ele confessou o tráfico, a venda de drogas, e indicou uma sacola ali perto com as drogas. Reconhece o réu e não o tinha visto antes da prisão.

Neste sentido foi o depoimento do policial Willian Carrieri alegou que o local é ponto conhecido de tráfico e por isso foram diligenciar. Entraram com viatura descaracterizada e o viram parado, atento, bem no ponto onde fica o vapor.

Abordado, não reagiu. Em conversa informal, ele respondeu que estava no tráfico e indicou um degrau bem próximo dele onde estava uma sacola com maconha e cocaína. Reconhece o réu e não o tinha visto antes naquela biqueira.

O réu, extrajudicialmente (fl.04), respondeu que não vende drogas, que não sabia que aquele local era um ponto de tráfico de drogas, que estava parado naquele lugar esperando por um amigo, mas nega-se a informar o nome do amigo, quando então foi abordado pelos policiais e trazido até esta delegacia. Declarou que apesar de ser usuário de drogas (maconha e crack), paga para uma terceira pessoa que estiver próximo a ele para que esta vá até a "biqueira" comprar a droga pra ele, razão pela qual não sabe onde ficam as "biqueiras" daquela região. Declarou que trabalha como ajudante de borracharia, em uma borracharia na Avenida Cursino, não sabendo indicar número ou nome da borracharia. Indagado se possui passagem criminal, o mesmo negou, porém declarou ter sido apreendido quando menor, no ano de 2017, por ato infracional assemelhado a tráfico de drogas, no mesmo bairro dos fatos desta data. Por fim declarou desconhecer as drogas apreendidas, que nada havia com ele quando de sua abordagem.

Sob o crivo do contraditório o acusado alegou que não sabia que tinha drogas ali. O policial veio com elas, que não estavam consigo. Nega ter indicado onde estavam as drogas. Só foi comprar as drogas com um conhecido que queria comprar e não sabia onde. Após ser questionado sobre sua versão extrajudicial, disse ter dado o dinheiro para um rapaz comprar drogas e ele foi embora com seu dinheiro, e como estava com cinco reais, foi comprar uma pedra de crack para si, e foi abordado pelos policiais enquanto aguardava o traficante. Às reperguntas do MP respondeu que está detido atualmente por tentativa de furto, em São Paulo.

Logo, os testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque a negativa de autoria tardia do acusado restou compeltamente isolada do contexto probatório, além de em nítida dissonância com sua versão extrajudicial, oportunidade em que alegou ter pago alguém para comprar droga para si por não saber onde ficava a biqueira e nessa audiência disse o contrário, ou seja, que um rapaz perguntou onde ficava a biqueira e o levava até lá. Ademais, é pouco crível que o réu tivesse ido no local para comprar droga para si depois do rapaz a quem havia pago para fazê-lo ter fugido com seu dinheiro sem que ele percebesse ou fosse atrás e, não por acaso e não por mera coincidência, acabou sendo preso no ponto de venda de drogas, porque segundo ele estaria esperando o traficante/vendedor chegar, o que também beira o fantasioso dado que o local é uma "loja"/biqueira onde se vende droga através de um vendedor que fica ali para isso. Inclusive, a Defesa não fez prova de nenhuma das três versões que o acusado trouxe.

E não se alegue que ausência de prévia denuncia anônima ou de apreensão de dinheiro sirvam à absolver o agente, pois como visto, ele estava numa biqueira já conhecida, em atitude suspeita, parado, sozinho, olhando ao redor, e ao ser abordado, teria confirmado que estava na prática de venda de drogas, tanto que indicou onde as escondia, num degrau próximo a si. Ademais, se o réu tinha cinco reais para comprar sua pedra de crack como alegou, então também é de se questionar o motivo da não apreensão desse numerário. E não havendo prova contrária ao conjunto probatório analisado acima, nem mesmo prova trazida pela Defesa no sentido de qualquer das versões do acusado, tem-se que a condenação se impõe.

Não bastasse isso, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais que gozam de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. E a defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as

declarações dos milicianos, não havendo portanto, motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Assim como não procede a tese de se tratar de mero usuário, ou seja, que o réu estivesse no local para comprar crack, posto que não demonstrado cabalmente como lhe competia o ônus dessa prova. Ademais, a condição de usuário de drogas não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o envolvimento anterior do réu com o crime, são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, assim como a quantidade de narcótico apreendido (71 no total) que é alto, mas não reputo excessivo às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, contudo diante da certidão de fl. 31/33 e de fl. 148 denota-se que o réu já teve passagem criminal na Vara da Infância e Juventude e por outro crime quando maior de idade, estando atualmente preso por um quarto delito já, tudo a indicar que o crime em tela não se trata de uma fato isolado em sua vida, tudo a demonstrar sua má personalidade, e para uma mais justa individualização da pena, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo, qual seja, em 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes. E quanto à citada na exordial, do art. 61, II, "j", do CP, embora os fatos tenham se dado em época da pandemia pelo Covid 19, entendo não haver prova cabal de que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, dessa situação especial à prática delitiva, ou que tenha se valido da facilidade que dela decorreu como: dificuldade de policiamento, menor cuidado por parte da vítima, a merecer maior grau de reprovabilidade da conduta. Ademais, não houve invasão da esfera de individualidade de terceira pessoa. Neste sentido vide: Por unanimidade, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a agravante de crime cometido em período de calamidade pública, conforme o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois, segundo o relator, desembargador Andrade Sampaio, "não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19" (TJ-SP / Proc. 1512067-20.2020.8.26.0228). E ainda se trata de uma biqueira estabelecida antes da pandemia e que persiste independente e inobstante a calamidade pública, de modo que não há prova cabal do nexa causal.

Presente a atenuante da menoridade relativa (fl. 09), a reduzir a pena ao mínimo

legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). E não há que se falar em confissão, já que o réu nessa audiência ele negou os fatos e negou tê-los confessado informalmente aos policiais.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu, faz jus ao beneplácito legal, porquanto seja ainda primário (fls. 96/98), mas considerando o tipo de droga, especialmente a cocaína de maior nocividade, alto poder viciante e degradante do ser humano, e a indicar maior envolvimento com a mercancia, como se vê patente a fl. 31/33 e 148, medida sócio educativa aplicada ao réu quando adolescente, por crime equiparado, além do fato dele ter sido solto nesse processo e mais uma vez foi preso, condenado, e encontra-se novamente preso, opto pelo percentual de 3/5 a reduzir a reprimenda para 02 anos de reclusão e 200 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Incabível a benesse do art. 44 do CP ao réu, por não se mostrar socialmente recomendável, tratando-se de uma ação de extrema gravidade, quanto mais diante da falta de consideração dele com o benefício de sua soltura, voltando a delinquir, o que indica que não cumprirá com eventual pena restritiva de direitos. Some-se a isso o fato de que : ... O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Fixo o regime prisional semiaberto por conta da razoável quantidade e variedade das drogas (71 no total) e das circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do CP (má personalidade do agente). Segundo entendimento do STJ já firmado, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e da quantidade da droga. Ainda, o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, por isso fixei o regime semiaberto ao agente que reitera no crime e faz dele seu meio de vida.

Vedo o recurso em liberdade, pois solto (fl. 45/47) descumpriu com as condições de sua liberdade provisória, sendo preso novamente, e já condenado por um terceiro crime, inclusive. Assim, para a garantia da ordem pública e para a devida aplicação

da lei penal, determino que o réu se recolha à prisão se pretender recorrer. Expeça-se o necessário.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra PEDRO HENRIQUE FERNANDES LOBO, qualificado à fl. 06, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 200 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Absolvo PEDRO HENRIQUE FERNANDES LOBO, das penas do art. 61, II, alínea j, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a assistência pela DPE.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Expeça-se mandado de prisão contra si. Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias

Oficie-se ao IIRGD e TRE. Determino, ainda, a incineração dos entorpecentes.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA